

1511207-82.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha -

Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº

11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511207-82.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511207-82.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autora:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE DE LIRA SILVA e GUSTAVO RAMON SANTANA

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

KAIQUE DE LIRA SILVA e GUSTAVO RAMON SANTANA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal, porque teriam, no dia 4 de maio de 2021, por volta de 20h30min, no interior da Estação da Luz, Bom Retiro, nesta cidade e Comarca, durante a vigência do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do covid-19, previamente ajustados e em identidade de desígnios entre si, mediante destreza, subtraído para si o celular modelo iPhone 7 Plus pertencente a Cristiano G. S.. Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 81/83).

Recebida a denúncia (fls. 120/121), os réus foram regularmente citados (fls. 149 e 150) e apresentaram resposta à acusação, Gustavo por meio da Defensoria Pública (fls. 186) e Kaique através de defensor constituído (fls. 189/191), ratificado o recebimento da denúncia, tendo Gustavo constituído defensor no curso do feito. Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido os réus interrogados.

Foi instaurado e regularmente processado incidente de insanidade mental do acusado Kaique (fls. 192/193), em que veio o laudo de fls. 263/269 , acerca do qual ouvidas as partes, homologado a fls. 260.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação dos acusados, nos termos da denúncia; pediu a defesa de Kaique, frente à confissão, que fosse compensada a reincidência pela confissão, sendo tomada detração, facultado recurso em liberdade (fls. 282/283); pleiteou a defesa de Gustavo a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente que fossem afastadas qualificadoras, não caracterizadas ou comprovadas, sendo penas fixadas no mínimo, atenuadas por menoridade relativa e confissão, em regime brando tomada detração, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria, incidindo as qualificadoras apontadas na denúncia, bem comprovadas, verificada a plena imputabilidade dos réus.

O réu Gustavo, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 17), ouvido em Juízo, admitiu a prática do furto, junto com Kaique e outros dois comparsas; empurrou a vítima, outro comparsa pegou o celular e passou para Kaique; quando estava subindo a escada para a saída com Kaique, foram abordados pelos agentes da CPTM, o celular foi apreendido com Kaique, os outros dois comparsas surgiram; confessaram desde logo a prática do furto; conhecia Kaique havia 2 ou 3 meses, da rua, não conhecia os comparsas até então; pretendiam vender o celular, venderiam na rua para haitianos e repartiriam o dinheiro, usaria o seu para pagar o aluguel da pensão onde morava; morava sozinho; não conhecia vítima ou testemunhas; tem dois processos anteriores por furto; expressou arrependimento. 19 anos

O réu Kaique, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 18), ouvido em Juízo, admitiu a prática do delito junto com Gustavo, estavam em quatro, Gustavo empurrou a vítima, outro comparsa apanhou o telefone e lhe passou, sendo que saiu com Gustavo por uma das saídas, enquanto os outros dois saíram por outro local; pretendiam vender o celular e repartir o produto entre todos, os comparsas sabiam a quem vender; usaria sua parte comprar drogas e alimentos; conhecia Gustavo havia cerca de 2 meses, da rua; era usuário de cocaína, mas conseguiu ficar sem usar, tinha estado numa casa de recuperação chamada Crack Zero, por cerca de um mês e meio; tem TDAH, tratou quando era criança; morava com sua mulher, que tem 21 anos, não têm filhos juntos; trabalhou como vendedor de loja por 2 meses em 2017, trabalhou depois como estagiário em loja de autopeças em 2018, desde então vinha vendendo chocolates no metrô; estufou até o 1º ano do ensino médio, parou por causa da pandemia; não conhecia vítima ou testemunhas; tem processos anteriores por furto; expressou arrependimento. 22 anos

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que, a par de ter ratificado a identificação do réu Gustavo a que havia procedido em reconhecimento formal (fls. 14), relatou que desembarcou do trem, por volta de 19h, estando a estação muito cheia, e dirigiu-se às escadas; colocou o celular no bolso da frente das calças enquanto foi passar álcool nas mãos; quando chegou ao topo da escada, deu falta do celular, notou o réu Gustavo a seu lado encarando-o, mas não pôde identificar quem havia pego o celular, então foi embora; não sentiu a retirada do celular de seu bolso; cerca de uma hora depois, telefonou ao celular e foi informado de sua apreensão; voltou à estação, onde reconheceu o réu Gustavo, não

pôde identificar o réu Kaique, que não havia visto no momento da subtração; o celular foi recuperado.

As circunstâncias da prisão dos réus e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos agentes de segurança da CPTM ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O encarregado de segurança da CPTM Alexandre descreveu em Juízo que estavam de serviço na Estação da Luz quando foram informados de um furto na linha amarela, dadas as características dos agentes; viram os réus saindo da estação para a Avenida Casper Líbero, por onde comumente saem os furtadores, e abordaram ambos; na cintura de Kaique encontraram o celular, o qual ele disse que tinha comprado e ia levar para desbloquear, porém ele estava também com outro aparelho; o celular apreendido tocou, era a vítima, que solicitaram que comparecesse na estação; sabendo que a vítima viria, os dois réus confessaram que tinham furtado o celular na escadaria, Kaique tinha apanhado o celular enquanto Gustavo empurrava a vítima. O agente de segurança da CPTM William relatou em Juízo que tinham informações compartilhadas em grupo de whatsapp quanto a pessoas envolvidas em furtos, não se recordava se os réus apareciam; no dia dos fatos, na Estação da Luz, foram informados pela central de monitoramento de um furto; os furtadores habitualmente saem da estação pela saída para a Avenida Casper Líbero, então postaram-se ali e viram os dois subindo para a saída; abordaram os réus e encontraram na cintura do réu Kaique um aparelho celular, que ele disse que havia comprado; o telefone tocou, era a vítima, que solicitaram que comparecesse na estação, então ambos os réus admitiram o furto, dizendo que Gustavo havia empurrado a vítima enquanto Kaique havia apanhado o celular, mencionando que haviam mais dois comparsas envolvidos no furto; ao chegar ao local, o ofendido apontou Gustavo, mencionando que quando deu pela falta do celular viu esse réu ao lado, mencionando inclusive que ele estava com um celular com a tela quebrada, sendo que de fato apreenderam um celular assim com esse réu.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os agentes de segurança da CPTM alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente das testemunhas e que estas não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que vítima e testemunhas mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, que nem conheciam, assomando claro que vieram a Juízo imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Bem esclarecido, assim, que os réus realmente praticaram juntos a subtração e que foram surpreendidos pouco tempo depois do furto tendo consigo o telefone celular furtado.

É cediço que a apreensão da res em poder dos acusados gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame, em que, ao contrário, os réus admitiram a autoria do crime. No que toca ao reconhecimento, é de se ver que a vítima, comparecendo ao local em que estavam os réus em seguida à apreensão com eles do telefone, identificou Gustavo de modo direto, espontâneo, afirmando com convicção tratar-se do indivíduo que viu logo a seu lado quando do furto e de que desde logo desconfiou. O reconhecimento assim ocorrido direto não reclama formalidade qualquer, que, dada a situação, seria de todo despicienda de utilidade.

A forma preconizada pelo artigo 226 do Código de Processo Penal visa assegurar a espontaneidade da identificação do agente pela vítima. Já identificado o agente Gustavo pela vítima no local da prisão, ausente dúvida na mente do ofendido, o oferecimento de nova oportunidade, formal, para a mesma afirmação já não se reveste de sentido.

Diligência de reconhecimento é tipicamente policial, destinada que é à apuração da autoria de delito, ausente previsão ou necessidade de repetição da prova, submetida

a contraditório diferido, em Juízo, quando de ordinário a vítima prestaria seu depoimento com o réu presente na mesma sala de audiência.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima e pelos relatos coincidentes das testemunhas, a que conforme a confissão de ambos os acusados, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

A comparsaria restou evidente, compreendendo-se da própria conduta, caracterizada por atuação concatenada entre os agentes com repartição de atos de execução, o ajuste de vontades entre eles, caracterizada participação equivalente e igualmente importante de todos, ademais relevante a circunstância para incrementar o potencial de êxito da empreitada, incidindo a qualificadora.

A destreza merece ser reconhecida, clara a incidência da qualificadora desde que sobejamente demonstrado o emprego de especial habilidade para a cesso à res, caracterizados os gestos praticados por leveza e rapidez tais que não foi dado à vítima notar a tomada do bem, que foi retirado do bolso da frente de suas calças com tal leveza que o ofendido nem sentiu o movimento.

É certo que a consumação foi atingida, desde que conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desvigiada da res, retirada da vítima e levada pelos agentes quando tomaram rumo sem que ninguém os perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção dos agentes de segurança da estação, já inserida em desenrolar causal autônomo.

A condenação é de rigor.

Kaique é plenamente imputável, constando do laudo pericial em apenso que "pela observação durante o exame, confrontado com o histórico, antecedentes, exame psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se que o periciado não apresentava ao tempo da ação, assim como não apresenta atualmente, quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, DSM-V, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado incapacitante ou incompleto, doença ou distúrbio mental, transtornos psíquicos ou emocionais, dependência de álcool ou drogas, transtorno de personalidade antissocial ou de instabilidade emocional, nem de qualquer outro transtorno suficiente para alterar a capacidade de julgamento ou de interferir nos mecanismos contensores, nem há referências pregressas. Em nenhum momento apresentou síndrome de abstinência, sintomas de privação de uso ou sinais de tolerância às drogas; também não apresentou comprometimento de sua saúde física e/ou mental, nem de seus relacionamentos familiares, sociais, afetivos, culturais, laborativos, financeiros, administrativos ou patrimoniais em decorrência do uso de álcool e/ou drogas, assim sendo, não preenche os critérios diagnósticos para dependência de substâncias psicoativas relacionados e especificados nos mesmos ditames técnicos e científicos (CID-10, DSM-V, OMS e OPAS). Não apresenta ausência ou diminuição da pilosidade nasal ou lesões físicas, que estariam obrigatoriamente presentes em caráter permanente, em decorrência da quantidade, frequência e tempo de uso de drogas alegado (critérios físicos), não havendo, portanto, dependência de álcool ou drogas, sendo considerado, sob a ótica médico-legal psiquiátrica, IMPUTÁVEL para o delito descrito na denúncia.

Passo, pois, à dosagem das penas que serão impostas aos acusados.

Ao delito descrito pelo artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis aos acusados, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda a quem do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia, reformulado, nesse ponto, o entendimento desde Juízo.

Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado

algum efeito sobre a situação calamitosa.

Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela conduta do réu, não justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

No mesmo sentido: TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 1512777-40.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 15'6422-73.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; e TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, Apelação Criminal 1517341-62.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime semiaberto, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerado que noticiado o repetido envolvimento dos réus na prática de condutas assemelhadas, evidenciada pela ausência de vínculo de emprego algo duradouro a ausência de compromisso de ambos com vida ordeira, circunstâncias que, a par de obstarem a adoção de regime mais brando, impedem substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Cabe eleição do regime prisional mais gravoso mesmo quando, consideradas apenas para efeito de fixação do montante da reprimenda, não se tenham mostrado desfavoráveis as circunstâncias judiciais, que, de resto, recomendam a segregação plena inicial.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas dos acusados, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus KAIQUE DE LIRA SILVA, identificado a fls. 45, qualificado a fls. 18, e GUSTAVO RAMON SANTANA, identificado a fls. 44, qualificado a fls. 17, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena aos acusados, é patente o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intmem-se os réus para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeçam-se e encaminhem-se cartas de guia / aditamentos; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intmem-se. Comunique-se.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA